



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL – BARRA FUNDA
3ª VARA CRIMINAL

SENTENÇA

Vistos, etc.

Deivid Lima da Silva, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, *caput*, da Lei nº 11.343/06. Segundo consta, no dia 25 de julho de 2016, na Rua Leon Carvalho, 217, por volta das 14h30, o acusado guardava, para fins de tráfico, 21 porções de cocaína, e 1 de *crack*.

Determinada a notificação do réu (fls. 87), houve resposta (fls. 95) e a denúncia foi definitivamente recebida (fls. 99). Em audiências (fls. 119/121 e nesta data) foi colhida a prova oral e o réu interrogado, tendo as partes se manifestado em debates. Há laudo de exame do entorpecente a fls. 116/117.

É o relatório.

Decido.

A procedência da ação é de rigor, posto que autoria e materialidade estão suficientemente comprovadas.

A prova dos autos demonstra de forma cabal que o réu praticou os fatos imputados na denúncia, não merecendo acolhida quaisquer pretensões de desqualificar a palavra dos policiais.

De fato, os policiais ouvidos, contra quem não há nada de concreto nos autos, não havendo assim razão para dar às palavras destes agentes públicos menos valor que às de qualquer outro cidadão, foram uníssonos ao afirmar que fizeram campana no local dos fatos, conhecido ponto de tráfico, tendo avistado o réu ser abordado por pessoas, ir até dentro da viela, e em seguida retornar entregando algo às pessoas, em típica movimentação de tráfico. Abordado, o réu admitiu a mercancia, e indicou o local onde estava o entorpecente, escondido num muro.

E não há nos autos a indicação de qualquer razão que teriam os policiais para cometerem crime e colocarem suas carreiras em risco, imputando ao réu, a quem sequer conheciam, crime que não tivesse praticado.

Não há, portanto, qualquer razão para se desmerecer a palavra dos policiais.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL – BARRA FUNDA
3ª VARA CRIMINAL

Ainda, o laudo pericial atestou a natureza do entorpecente, e as circunstâncias do fato e da prisão do réu (especialmente a quantidade e forma de acondicionamento em porções separadas, além da movimentação vista pelos policiais, e a confissão informal do acusado) não deixam dúvidas de que se destinavam a fornecimento a terceiros, caracterizando assim o crime de tráfico, e sendo impossível a desclassificação do delito.

Ademais, a versão do acusado em seu interrogatório restou isolada de comprovação nos autos, sem nenhum elemento idôneo que a corrobore, carecendo, portanto, de qualquer credibilidade.

Tem-se, assim, um conjunto probatório forte e coerente em desfavor do réu, suficiente a gerar a convicção de que realmente ele guardava a droga citada na denúncia, e que o fazia para fins de tráfico, sendo de rigor sua condenação.

Assim, certa a condenação pelo artigo 33 da Lei nº 11.343/06, passo a dosar a pena.

Na fase do artigo 59 do Código Penal, e atento ao disposto no art. 42 da Lei nº 11.343/06, tenho que é necessária a fixação da pena base acima do piso legal.

O que indica a maior gravidade do delito, e recomenda uma exasperação da pena, é justamente a natureza das substâncias apreendidas. Diversas são as substâncias que caracterizam entorpecentes. Contudo, dentro dessas, há algumas que são mais graves, seja por terem maior poder de gerar dependência, seja por serem mais nocivas ao organismo do usuário.

Não há dúvidas de que a cocaína causa dependência com muito mais facilidade que a maconha, assim como gera maiores consequências para o organismo do usuário. Já o *crack* ou a heroína são ainda muito piores, causando forte vício a partir de poucas utilizações e sendo extremamente nocivos à saúde do usuário.

Embora todas sejam substâncias entorpecentes submetidas à Lei de Tóxicos vigente, não se pode negar que possuem características, seja quanto ao grau de dependência, seja quanto à nocividade, muito diferentes entre si, não podendo ser consideradas de forma absolutamente indistinta na dosimetria da pena correspondente, justamente porque não se pode dar o mesmo tratamento a quem



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL – BARRA FUNDA
3ª VARA CRIMINAL

comercializa uma substância extremamente nociva e viciante em relação a outra pessoa que repassa outra substância muito menos danosa, dado que são condutas que atingem de forma diversa os usuários e a própria sociedade.

Assim, em sendo o delito de tráfico de substância mais grave, a pena a ser aplicada, para quem explora o vício e gosto dos usuários, deve ser maior.

E não é demais lembrar que, quanto mais forte a dependência gerada pela substância, mais crimes serão cometidos para sustentar o vício dos dependentes, implicando assim, como dito, numa maior gravidade não só para quem usa o entorpecente, mas sim para toda a sociedade.

Desta forma, tenho aplicado para o tráfico de maconha, droga esta menos nociva, a pena no mínimo legal. Já para o tráfico de cocaína, aumento esta pena e, em se tratando de *crack*, aplico um aumento ainda maior, posto que a destruição nas vidas dos usuários desta substância, explorada pelo traficante, é muito maior.

Porém, no caso concreto, a quantidade não era elevada, razão pela qual tenho como razoável a elevação da pena em apenas seis meses, e 50 dias-multa.

Ausentes agravantes ou atenuantes.

O réu é primário, sem antecedentes, e não há comprovação definitiva de que fosse envolvido com organizações ou outras práticas criminosas. Não vejo, assim, óbice ao benefício previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

Quanto ao montante da redução, observo que se trata de questão polêmica, já que as circunstâncias que são utilizadas para a concessão ou não do benefício (primariedade, falta de antecedentes e não envolvimento com organizações criminosas nem se dedique a atividades desta natureza) são totalmente objetivas, e não admitem gradação. Ou seja, ou a pessoa atende integralmente aos requisitos, e faz jus ao benefício, ou não atende, e não faz jus. Não servem, portanto, para a escolha do montante de redução a ser aplicado.

Ademais, observo que não me parece que a intenção do



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL – BARRA FUNDA
3ª VARA CRIMINAL

legislador tenha sido a de beneficiar aqueles que realmente sejam traficantes “profissionais”, aplicando uma pena inferior à que era aplicável na legislação anterior, o que ocorre quando utilizado o redutor em dois terços. Pelo contrário, tudo indica que tal benefício deva ser reservado, especialmente em seus patamares mais elevados, àquelas pessoas, que tenham vida correta, sem nenhuma propensão ao crime, mas que, num momento absolutamente *isolado* e *ocasional*, tenham vindo a praticar um delito de tráfico de menor gravidade.

Assim, considerando a natureza do benefício, tenho que se deve considerar para fixação do patamar de redução o grau de eventualidade do delito indicado pelas circunstâncias do fato. Ou seja, se as circunstâncias dos autos indicarem que aquela sem dúvida alguma foi um ação completamente isolada e ocasional, o redutor deve ser aproximar do máximo. Seria o caso, por exemplo, de alguém que tenha atividade profissional definida, e que numa situação completamente específica tenha aceitado, uma única vez, fazer o transporte de entorpecente para outrem, e em quantidade não elevada, sem indicação de ligação com o tráfico organizado. Já, quando se evidencia que aquela não seria uma ação isolada de tráfico, mas sim algo que iria se repetir, ou mesmo atingir mais de uma pessoa, como no caso de alguém surpreendido com diversas porções num local conhecido como ponto de tráfico, então a redução deve ser menor. Pior ainda quando há também a participação de olheiros, ou “contabilidade” de comercialização, que denotem a proximidade com maiores traficantes, hipótese em que a redução deve se aproximar do mínimo, ou sequer ser aplicada, conforme as circunstâncias, se evidenciada a participação em organização criminosa.

No caso dos autos, o réu estava na prática do tráfico a varejo, em ponto conhecido, indicando não uma ação absolutamente isolada e ocasional, mas sim reiterada, razão pela qual a redução deve se afastar do máximo. Mas não há indicação de maior proximidade com o grande tráfico, não havendo razão para a redução no piso.

Assim, tenho como razoável e adequada a redução em metade, finalizando a pena do réu em 2 anos e 9 meses de reclusão, e 275 dias-multa.

Quanto às questões da liberdade provisória (o que alcança também o direito a recorrer solto), da possibilidade de substituição das penas



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL – BARRA FUNDA
3ª VARA CRIMINAL

privativas de liberdade e do regime inicial da sanção, observo que o Supremo Tribunal Federal vem, ainda que de forma não unânime (havendo valiosíssimos votos divergentes), afastou a inflexibilidade das disposições legais expressas (vedação da liberdade e das penas restritivas, bem como regime inicial sempre fechado).

E as razões de tais entendimentos vêm bem esclarecidas na seguinte ementa:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 44 DA LEI 11.343/2006: IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. OFENSA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA (INCISO XLVI DO ART. 5º DA CF/88). ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. O processo de individualização da pena é um caminhar no rumo da personalização da resposta punitiva do Estado, desenvolvendo-se em três momentos individuados e complementares: o legislativo, o judicial e o executivo. Logo, a lei comum não tem a força de subtrair do juiz sentenciante o poder-dever de impor ao delinqüente a sanção criminal que a ele, juiz, afigurar-se como expressão de um concreto balanceamento ou de uma empírica ponderação de circunstâncias objetivas com protagonizações subjetivas do fato-tipo. Implicando essa ponderação em concreto a opção jurídico-positiva pela prevalência do razoável sobre o racional; ditada pelo permanente esforço do julgador para conciliar segurança jurídica e justiça material.

2. No momento sentencial da dosimetria da pena, o juiz sentenciante se movimenta com ineliminável discricionariedade entre aplicar a pena de privação ou de restrição da liberdade do condenado e uma outra que já não tenha por objeto esse bem jurídico maior da liberdade física do sentenciado. Pelo que é vedado subtrair da instância julgadora a possibilidade de se movimentar com certa discricionariedade nos quadrantes da alternatividade sancionatória.

3. As penas restritivas de direitos são, em essência, uma alternativa aos efeitos certamente traumáticos, estigmatizantes e onerosos do cárcere. Não é à toa que todas elas são comumente chamadas de penas alternativas, pois essa é mesmo a sua natureza: constituir-se num substitutivo ao encarceramento e suas seqüelas. E o fato é que a pena privativa de liberdade corporal não é a única a cumprir a função retributivo-ressocializadora ou restritivo-preventiva da sanção penal. As demais penas também são vocacionadas para esse geminado papel da retribuição-prevenção-ressocialização, e ninguém melhor do que o juiz natural da causa para saber, no caso concreto, qual o tipo alternativo de reprimenda é suficiente para castigar e, ao mesmo tempo, recuperar socialmente o apenado, prevenindo comportamentos do gênero.

4. No plano dos tratados e convenções internacionais, aprovados e promulgados pelo Estado brasileiro, é conferido tratamento diferenciado ao tráfico ilícito de entorpecentes que se caracterize pelo seu menor potencial ofensivo. Tratamento diferenciado, esse, para possibilitar alternativas ao encarceramento. É o caso da Convenção Contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e de Substâncias Psicotrópicas, incorporada ao direito interno pelo Decreto 154, de 26 de junho de 1991. Norma suprallegal de hierarquia intermediária, portanto, que autoriza cada Estado soberano a adotar norma comum interna que viabilize a aplicação da pena substitutiva (a restritiva de direitos) no aludido crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

5. Ordem parcialmente concedida tão-somente para remover o óbice da parte final do art. 44 da Lei 11.343/2006, assim como da expressão análoga “vedada a conversão em penas restritivas de direitos”, constante do § 4º do art. 33 do mesmo diploma legal. Declaração incidental de inconstitucionalidade, com efeito ex nunc, da proibição de substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos; determinando-se ao Juízo da execução penal que faça a avaliação das condições objetivas e subjetivas da convalidação em causa, na concreta situação do paciente.

(HC 97256, Relator(a): Min. AYRES BRITTO, Tribunal Pleno, julgado em 01/09/2010, DJe-247 DIVULG 15-12-2010 PUBLIC 16-12-2010 EMENT VOL-02452-01 PP-00113 RT v. 100, n. 909, 2011, p. 279-333)

Ou seja, é evidente que um dos principais fundamentos do afastamento daquelas disposições legais inflexíveis foi a preservação do poder/dever de individualização das penas, nem de longe se podendo disso extrair que todo e qualquer tráfico de entorpecentes deva ser considerado como tendo a mesma gravidade e pelos



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL – BARRA FUNDA
3ª VARA CRIMINAL

mesmos critérios que qualquer outro delito, tais como um simples furto ou estelionato, por exemplo.

Ora, não se pode negar que tanto o Constituinte como o legislador ordinário sempre demonstraram que o tráfico de entorpecentes é um crime muito grave, e merece ser combatido com especial rigor. Vide nesse sentido não só os dispositivos atacados das Leis nº 11.343/06 e 8.072/90, como também os incisos XLIII e LI do artigo 5º da Constituição Federal.

Desta forma, tenho que a melhor interpretação das decisões do Supremo Tribunal Federal, com o necessário e imprescindível respeito à vontade da sociedade expressada pelo legislador é a de que o sentido daquelas determinações específicas (maior rigor) deva ser a base de aplicação das penas para o crime de tráfico, mas com a flexibilidade de que, em situações diferenciadas de menor gravidade, se possa, em caráter excepcional, abrandar as sanções aplicáveis.

O tráfico de entorpecentes é uma atividade extremamente lucrativa, e a sanção para tal delito deve ser proporcional ao benefício que ele proporciona a quem o pratica, sob pena de prejudicar o objetivo da pena de dissuadir deste tipo de conduta.

Agir de outra forma, tratando o tráfico de drogas exatamente pelos mesmos critérios que qualquer outro delito não hediondo ou equiparado implicaria em transformar em letra morta as disposições, orientações e princípios contidos na Constituição Federal sobre tal delito.

Ora, no caso concreto, como já acima dito, as circunstâncias não indicam um crime de menor gravidade, praticado de forma absolutamente isolada e ocasional, por pessoa com comprovada atividade lícita, mas sim a prática de tráfico a varejo, potencialmente atingindo diversos usuários, comercializando substâncias mais nocivas, e com intuito egoísta de lucro.

Por isso que, no caso específico dos autos, aplico o regime fechado como inicial, sendo negada a substituição da pena privativa de liberdade, tornando assim a sanção proporcional à gravidade do delito praticado, e em efetivo desestímulo a que não só o réu, mas mesmo outras pessoas, venham optar por este extremamente lucrativo e pernicioso delito.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL – BARRA FUNDA
3ª VARA CRIMINAL

Porém, tendo ele respondido solto, e comparecido em juízo, poderá apelar desta forma.

Isto posto, julgo a presente ação PROCEDENTE, para condenar **Deivid Lima da Silva**, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, *caput*, da Lei nº 11.343/06, à pena de 2 anos e 9 meses de reclusão em regime inicial fechado, observada a progressão diferenciada, e 275 dias-multa, estes no mínimo legal.

O réu poderá apelar em liberdade.

Não havendo impugnação ao laudo pericial, inexistindo assim dúvida sobre a natureza da droga e considerando as precárias condições de acondicionamento destas substâncias nas Delegacias de Polícia, determino que caso ainda não tenha sido feito, **oficie-se, independente do trânsito em julgado, comunicando a autorização para incineração dos entorpecentes apreendidos.**

Determino, outrossim, o perdimento dos valores apreendidos em favor da União, nos termos da Lei de Tóxicos, a ser comunicado após o trânsito em julgado.

Custas pelo condenado, na forma do artigo 4º, § 9º, *a*, da Lei nº 11.608/03, ressalvada eventual inexigibilidade em caso de pobreza, nos termos do artigo 12 da Lei nº 1.060/50, que fica presumida pela atuação da Defensoria Pública.

P.R.I.C.

São Paulo, **8 de fevereiro de 2017.**

Juiz de Direito: Dr. **Carlos Eduardo Lora Franco**

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
 CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**

Ciente:

Ministério Público:

Réu(s):

Defensor(es):